

ערעור אזרחי מס' 491/76

גאולים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

נגד

ידידיה צדוק

בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

[25.8.77, 3.12.76]

לפני השופטים שמגר, אשר, בן-פורת

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, ס"ח 16, סעיפים 6, 7, 7(ב), 8 - חוק השליחות, תשכ"ה-1965, ס"ח 220, סעיף 14 - פקודת הבוררות, חא"י (ע) 35, (א) 40 [בוטלה: ס"ח, תשכ"ח, 184], סעיף 3 - חוק הבוררות, תשכ"ח-1968, ס"ח 184, סעיפים 12(א), 10-8.

מיני-רציו:

* בוררות – בורר – התפטרות

* בוררות – הסכם בוררות – ביטול

* חוזים – ביטול – תוצאתו

בהחלטה נשוא הערעור הגיע בית-המשפט המחוזי למסקנה שעל הבורר להתחיל בבוררות, ואם לא יסכים, יוכל המשיב לפנות לבית-משפט לשם מינוי בורר חליף במקום הבורר שהתפטר.

בית-המשפט העליון פסק:

א. (1) אין צד לבוררות רשאי לבטל אותה אחרי שהבוררות נתכוננה והבורר החל לפעול על-פי שטר-הבוררין, אלא בהסכמתו של הצד האחר או באישורו של בית-המשפט.

(2) שטר-בוררין אינו מטיל, בדרך-כלל, התחייבויות מהותיות על הצדדים, אלא קובע איך ליישב סכסוכים ביניהם.

(3) מן הרגע שהבוררות נתכוננה היא חיה את חייה העצמאיים והיא כפופה לחוק מיוחד, הוא חוק הבוררות, ולא לחוקי החוזים.

(4) אין הצדדים לבוררות יכולים לאכוף על בורר שימשיך לכהן בתפקידו כבורר ואינם יכולים למנוע את התפטרותו.

(5) כאשר מתפטר בורר מתפקידו, רשאי כל צד לבוררות לבקש מבית-המשפט שימנה בורר חליף.

(6) העיון בהסכם דנן מראה בעליל שכוונת הצדדים היתה למנוע מינויו של בורר חליף.

(7) ההסכם דנן, שכלל את שטר-הבוררין, לא בוטל כדין, כאשר לא ניתנה הודעת-ביטול לאחר תום תקופת הארכה.

ב. (אליבא דשופטת בן-פורת) (1) המוסמך לקבוע שהסכם בוררות בטל, או שבוטל כדין, הוא לא הבורר כי אם בית-המשפט, אלא אם הסכימו הצדדים עצמם לביטולו.

(2) חובת הראיה שסמכות הבורר בוטלה כדין רובצת לפתחו של הטוען כך.

(3) הסכם בוררות, ככל הסכם אחר, ניתן לביטול על-סמך הפרה יסודית, או לאחר הודעה מתאימה בעקבות הפרה לא-יסודית.

(4) ביטול הסכם הבוררות דנן נעשה כדין, וההסכם אכן בוטל.

פסקי-דין של בית-המשפט העליון שאוזכרו:

[1] בר"ע 130/71 עזרא משה משיח נ' שלמה שאול רביע, ואח', פ"ד כה(2) 572,

פ"ד כה(2) 574, פ"ד כה(2) 575.

[2] ע"א 207/76 מילק נחמן הרשקו נ' יעקב וכטר, פ"ד לא(2) 85, פ"ד לא(2) 93,

פ"ד לא(2) 96.

[3] ע"א 594/75 חיים ג'רבי נ' יפה הייבלום, פ"ד ל(2) 673, פ"ד ל(2) 675,

פ"ד ל(2) 681.

[4] ע"א 557/75 אמיר אגני נ' מרדכי כהן, פ"ד ל(2) 64.

[5] ע"א 2/49 ניסן רודה נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד ג 201, פ"ד ג 209; פ"ע ה 185.

פסקי-דין אנגליים שאוזכרו:

[6] HEYMAN AND AN. V. DARWINS, LTD. (1942) 1 ALL E.R. 337;

(A.C. 356; 111 L.J.K.B. 241; 166 L.T. 306; 58 T.L.R. 169) 1942

(H.L.).

הערות:

להתפטרות בורר, עיין: בר"ע 124/68, 125/68 אליעזר שחב, ואח' נ' יחיא ו-משה שחב; יעקב שחב, ואח' נ' יחיא ו-משה שחב, ואח', פ"ד כג(1) 16.

ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי, תל-אביב-יפו, מיום 4.7.76, ב-המ' 4817/76. הערעור נתקבל.

א' ירון - בשם המערערות;

ב' לנדה - בשם המשיב

פסק-דין

השופטת בן-פורת: המשיב, מר ידידיה צדוק, פנה אל בית-המשפט המחוזי, תל-אביב-יפו (המ' 817/76) בבקשה על דרך המרצה נגד "גאולים, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ" (המערערת, שתכונה האגודה), "למנות את מר יחיאל אדמון ו/או את מר אריה מועלם להיות בורר בין המבקש והמשיב". לחלופין ביקש להורות לאותו מועלם להמשיך בהליכי הבוררות, או ליתן כל סעד אחר שייראה לבית-המשפט. בנימוקיו ציין שהוא מחזיק בנחלה (כולל דירה) במושב גאולים וכי האגודה השיגה בבית-המשפט (ב-ת"א 2104/71, נתניה) פסק-דין המצווה עליו לפנות את המקום. הוא מצדו הגיש בקשה (ב-המ' 281/74) לבטל אותו פסק-דין אשר ניתן (בלשונו) "שלא בפניו". בינתיים נחתם בין הצדדים ביום 23.6.1975 הסכם בוררות (נספח א' לבקשה) ועל-פיו מונה מועלם הנ"ל לשמש כבורר. אולם הלה דרש שהצדדים יחתמו על שטר-בוררין נוסף, דרישה שהמבקש נענה לה, אך האגודה סירבה בטענה שהסכם הבוררות הופר על-ידי המבקש ועל-כן בוטל. המבקש פנה למועלם להמשיך בהליכי הבוררות, אך נענה, כי עקב ביטול ההסכם על-ידי האגודה אין הוא יכול לעשות כן. במקביל, פנה בא-כוח המבקש לבא-כוח האגודה והודיעו על רצון שולחו "להמשיך הבוררות וכן על נכונותו לקיים כל תנאי שידרש ממנו", אך האגודה הודיעה באורח חד-צדדי על ביטול ההסכם.

בתצהיר התשובה (מפי עמנואל זר-אביב) טענה האגודה שצדוק הפר את הסכם הבוררות (בלשונו - "לא קיים אותו בכלל") שכן: (א) הוא ואשתו לא חתמו על בקשה להתקבל כחברים באגודה, כפי שהתחייבו לעשות בסעיף 3 להסכם- הבוררות; (ב) הוא לא שילם לאגודה את החוב הפסוק ב-ת"א 2110/71, כפי שהתחייב לעשות בסעיף 16 להסכם; (ג) הוא לא ביקש את הוועדה המקומית והמחוזית להשעות את הדיון בתכנית שהגיש לגבי השטח הנדון כפי שהתחייב לעשות בסעיף 15(א) להסכם, ואף המשיך בפעילותו זו. על-סמך ההודעות, האזהרות והארכות מאת האגודה, שצדוק לא שעה להן - לרבות בישיבה שקיים הבורר ביום 8.10.1975 - ובעיקר לאור הודעתו המפורשת שאין הוא מוכן כלל לקיימן, זכאית היתה האגודה להודיע על ביטול הסכם הבוררות, כאשר עשתה. צדוק איחר את המועד כאשר ביקש את הבורר כעבור חדשים רבים להמשיך בהליכי הבוררות, בהביעו נכונות לקיים את התחייבויותיו והביטול בעינו עומד.

השופט המלומד החליט כי הבורר טעה בדרישתו שהצדדים יחתמו על שטר-בוררות, במקום להסתפק בהסכם הבוררות החתום (מסקנה שעוד אתייחס אליה). מאידך טענה האגודה בסברה כי הפרת התניות דלעיל הצדיקה ביטולו של הסכם הבוררות, שכן -

"בשום מקום לא נאמר בהסכם הבוררות כי יש תנאי מוקדם לקיום הבוררות. כל תנאי ההסכם אחוזים ושלובים זה בזה כשבראש כולם וכמוביל לכולם התנאי העיקרי שהבוררות תתקיים. אין הועד (הכוונה ל'אגודה' - מ' ב') יכול לתלוש מתוך ההסכם מספר סעיפים ולהתייחס אליהם באופן

שרירותי כתנאים עקריים ולהתנות את הליכתו לבוררות בקיומם המוקדם על-ידי מר צדוק. אמת המידה של מועד קיום התנאים אין אף בה כדי לקבוע שהבוררות לא תתקיים אם לא יתקיימו אלו תחילה. מחובת המושב היה להמשיך בהליכי הבוררות ולתבוע את קיום תנאי ההסכם שהוטלו על צדוק. ואולם לא היתה למושב סמכות לבטל את הבוררות או להימנע מלקיימה בשל כך.

על יסוד הלך מחשבה זה הגיע השופט המלומד למסקנה שעל מועלם לזמן את הצדדים ולהתחיל בבוררות, ואם לא יסכים - יוכל לפנות אל בית-המשפט שימנה בורר אחר תחתיו.

על החלטה זו נסב ערעורה של האגודה המונח לפנינו.

2. לדעתי יש לערער על מה שיסמוך.

לאחר הודעת-הביטול מאת האגודה צדק לדעתי הבורר כאשר סירב להמשיך בבוררות, אלא אם יחתמו הצדדים על שטר-בוררין. עד להודעת-הביטול הוא החל למלא תפקידו ואף קבע מועד להגשת טענותיהם של שני הצדדים. אולם לאור המחלוקת באשר לקיומו או בטלותו של הסכם-הבוררות, נבצר ממנו להמשיך בהליכים. כבר הבהיר בית-משפט זה (בין היתר) ב-[ר"ע 130/71](#), [1], בע' 575-574, מפי מ"מ הנשיא (זוסמן) (כתארו אז) כי -

"..... דין הוא, שמקום שסמכות הבורר מוטלת בספק, נבצר מהבורר לפסוק בכך. סמכות השיפוט של בורר נובעת מהסכם בוררות בר-תוקף; אם ישלול הבורר תקפו של חוזה המכיל הסכם הבוררות, יוצא שלא היה מוסמך לכך, שכן באין הסכם בוררות, אינו רשאי לדון, וממילא אינו יכול להכריע בסמכותו הוא, אף לא לשלילה. מאותו טעם גופו, שהסכם בוררות בר קיימא תנאי מוקדם לשיפוט הבורר הוא, אין הבורר יכול גם לחייב את תקפו של ההסכם" (ההדגשות שלי).

בקטע דלעיל מדובר בחילוקי-דעות באשר לתקפו של חוזה המכיל סעיף בוררות, למקרה שיתגלעו סכסוכים הנובעים מן ההסכם. הכוונה היא לבטלות או לביטול מחמת מצג-שוא, טעות, אי-חוקיות וכו'. לעומת זאת ברור שתקפו של חוזה כזה אינו פג רק משום שאחד הצדדים טוען שהצד האחר הפר אותו וכי עקב כך בוטל. ההפרה אך מקימה לצד המקיים עילת תביעה - בין לביצוע-בעין ובין לפיצויים, אותה עליו להביא בפני הבורר. וכך יש לדעתי להבין את פסק-הדין, [6] HEYMAN, המצוטט על-ידי חברי הנכבד השופט אשר, שכן דן גם הוא, כנאמר בציטוט, ב"סעיף בחוזה בדבר בוררות".

שונה המצב כאשר מדובר לא בסעיף בחוזה המוסר סכסוכים שיתגלעו בין הצדדים (אם יתגלעו) לה כ-

רעתו של בורר - מסירה שהיא גופה סתמית ובלתי-מותנית - אלא במסירת סכסוך קיים להכרעתו של בורר על-פי תניות המפורטות בהסכם-בוררות.

במקרה האחרון מסירת ההכרעה לבורר אינה בלתי-מותנית אלא כפופה לקיום ההתחייבויות שבהן הותנתה. אם שאלת ההפרה של הסכם בוררות אשר כזה היא השנויה במחלוקת, או המוטלת בספק, חל הכלל כפי שהוסבר ב-[בר"ע 130/71](#), [1], היינו: לא הבורר אלא רק בית-המשפט הוא המוסמך לפסוק בשאלה.

לשון אחרת: המוסמך לקבוע שהסכם בוררות בטל, או שבוטל כדין, הוא לא בורר כי אם בית-המשפט, אלא אם הסכימו הצדדים עצמם לביטולו (ראה גם ספרה של ד"ר אוטולנגי "על בוררות", סעיף 58, בע' 48).

3. חובת הראיה שסמכות הבורר בוטלה כדין רובצת לפתחו של הטוען כך, בענייננו - האגודה. כנאמר ב-[בר"ע 130/71](#), [1], הנ"ל:

"לא הבורר, כי אם בית-המשפט חייב לפסוק בטענה, ואם לא הראה הטוען, כי הסכם הבוררות בוטל, לא ימנע בית-המשפט את קיום הבוררות בהתאם להסכם" (ההדגשה שלי).

השאלה בפנינו היא איפוא אם עלה בידי האגודה להוכיח כי הסכם-הבוררות בוטל כהלכה, שאם לא הרימה נטל זה הרובץ עליה, כי אז יש להורות על קיום הבוררות (בכפוף לטענה נוספת מטעם האגודה שעליה אעמוד, במידת הצורך, בנפרד).

אי-קיום ההתחייבויות, כמפורט בתצהיר התשובה של האגודה, אינו כשלעצמו במחלוקת. צדוק אינו טוען שהוא ואשתו הגישו בקשה להתקבל כחברים באגודה תוך שבעה ימים למן חתימת ההסכם, כמצוות סעיף 3 להסכם הבוררות, כן אין בפיו טענה שסילק "מיד" את החוב הפסוק, בהתאם לסעיף 16, או שביקר את הרשות (המקומית והמחוזית) להפסיק עד להכרעה בסכסוך את הדיונים בתכנית לגבי שטח המריבה, כמצוות סעיף 15(א). לדעתו מותר לו לעמוד על כך שקודם כל תתקיים הבוררות (עמדה שעשה באיחור רב נסיון חלקי לסגת ממנה). השופט המלומד לא היה שלם עם גישה זו ועל-כן הבהיר בסוף החלטתו כי -

"על מר צדוק למלא את התחייבויותיו לפי ההסכם ללא כל קשר עם קיום הבוררות. מי שתובע את מילוי ההסכם בקשר לבוררות צריך (כתוב 'צדוק') לעשות את חלקו בעסקה - ולבצע את התחייבויותיו הוא להסכם וטוב יעשה מר צדוק אם יעשה זאת ללא דיחוי נוסף".

אולם חרף דברים אלה, ראה (כזכור) השופט המלומד את הסכם הבוררות כמיקשה אחת, שאין לעקור מתוכה "באופן שרירותי" תנאים מסויימים ולראותם כיסודיים, ואת הפרתם - כעילה לביטול.

בכך נתפס השופט המלומד לטעות. הסכם-הבוררות, ככל הסכם אחר, ניתן עתה לביטול על-סמך הפרה יסודית, או לאחר הודעה מתאימה בעקבות הפרה לא-יסודית:

סעיפים 6 ו-7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). תשל"א-1970, כפי שפורשו לאחרונה ב-**ע"א 207/76**, [2]. משהפר צד את הסכם-הבוררות ועקב כך השתמש הצד המקיים בזכות הביטול, אין לומר שסמכות הבורר היא בגדר שליחות שאין לבטלה משום שזכותו של צד שלישי תלויה בו (**סעיף 14 לחוק השליחות**, תשכ"ה-1965). הפרתו של "בעל-הזכות" אינה יכולה לשמש לו תריס ומגן שכן ניתנה ההסכמה מלכתחילה (כמוסבר לעיל) בכפוף להתחייבויות שאותן הפר.

טול, למשל, את ההתחייבות להגיש תוך שבעה ימים בקשת הצטרפות לאגודה (**סעיף 3 להסכם-הבוררות**). התחייבות זו כלל לא היוותה נושא להכרעתו של הבורר, שכן מדובר בסעיף 4 להסכם-הבוררות על מסירתם לבורר של שאלות וענינים "שיפורטו להלן", הוזה אומר - להוציא סעיף 3. החשיבות שייחסו הצדדים להתחייבות זו באה לכלל ביטוי גם בכך, שהוסכם כי הבקשה לא תהיה ניתנת לביטול, אלא אם כן לא יתמנה בורר (**סעיף 6(ב)**, סיפא). ואכן, הבקשה חיונית לאור השאלות והענינים שנמסרו להכרעתו של הבורר, כמפורט בסעיף 7 להסכם-הבוררות, למשל, לפי סעיף 7(ג) שעליו להכריע -

"..... האם יש לקבל את צדוק ואשתו כחברים באגודה או שהם יהיו תושבים בגאולים במעמד של, עובדי ציבור, או 'בעלי מקצוע'."

משימתו העיקרית של הבורר היתה להחליט אם לבצע את פסק-דין הפינני הנזכר לעיל, או לאו. אולם ברור שלשאלת חברותם באגודה של צדוק ואשתו עשויה להיות השפעה ניכרת על עמדת הבורר בענין מרכזי זה.

לא בכדי קבעו הצדדים שהבקשה תוגש תוך שבעה ימים, אם כי למינוי הבורר הוקצבו שלושה חדשים. גם מכאן עולה הכוונה שהבקשה תהא קיימת כבר בעת שימונה הבורר. הוא, לדעתי, הדין גם בהתחייבות לסלק את החוב הפסוק ולהקפיא את הדיון בתכנית שהגיש צדוק לרשות המקומית. גם אלה לפי טיבם אינם ענין לבורר לענות בו, אלא התחייבויות פשוטן כמשמען שצדוק חייב היה לקיימן, מיד או בהקדם, כחלק מהסכם הבוררות.

אם ירדתי לסוף דעתו של השופט המלומד, הרי שראה בחיובי הצדדים "חייבים מקבילים" או "שלובים" (CONCURRENT) ועל-כן סבר שאין להפריד בין הדבקים ויש לקיים את הבוררות על-אף ההפרות.

מסקה זו אין בידי להצדיק. אף בהנחה שהחייבים הם "מקבילים", חרף המועדים השונים להשלמת ביצועם, די בכך שהאגודה מצדה מילאה בנאמנות (או היתה מוכנה למלא בנאמנות) את המוטל עליה, כדי שתקום לה זכות הביטול לאור סירובו של צדוק

לעמוד בהתחייבויותיו הוא: [ע"א 594/75](#), [3], בע' 675, מול האות א וכן ע' 681, מול האות ה. לשון אחרת: הדעת נותנת שאילו חזתה האגודה מראש, בעת החתימה על הסכם-הבוררות, שצדוק לא יקיים את ההתחייבויות דלעיל, לא היתה מתקשרת. באמרי כך שיוותי לנגד עיני את האדם הסביר כשהוא ניצב בנעלי האגודה במעמד הקשר:
[סעיף 6 לחוק התרופות](#) הנ"ל וכן [ע"א 207/76](#), [2], הנ"ל.

אולם באין קביעה מפורשת בהסכם הבוררות, שאי-קיום ההתחייבויות דלעיל במועדן יהווה הפרה יסודית של ההסכם, היטיבה האגודה לעשות כאשר לא הזרזה לבטל את הקשר והעדיפה לתת לצדוק התראה וארכה בצדה.

בכך, קיימה את המוטל עליה לפי [סעיף 7\(ב\) לחוק התרופות](#) הנ"ל ומכאן שהביטול הוא כדין, ובידוע שהודעת-ביטול אינה חייבת להיות פורמלית: [ע"א 557/75](#), [4].
אין גם לומר כי בנסיבות הענין היה ביטול החוזה בלתי-צודק (כלשון חלקו האמצעי של סעיף זה).

הודעתו של צדוק לבורר ולאגודה מיום 29.7.1976 (נספחים ג' ו-ה' לבקשתו), שאם ימשיכו בהליכי הבוררות, יהיה מוכן לבצע התחייבויותיו, היא חסרת כל נפקות משפטית ואין בכוחה להקים לתחיה הסכם שבוטל למעלה ממחצית השנה קודם לכן.

4. יצויין, רק למען שלמות הדיון, כי ב**פקודת הבוררות**, שקדמה לחוק הנ"ל, קבע סעיף 3 לאמור:

"אם לא פורשה בשטר-בוררין כוונה האומרת את ההיפך, הרי אין לבטלו אלא ברשות בית המשפט או בהסכמתם של הצדדים ויהא לו תוקף מכל הבחינות ממש כאילו היה זה צו בית המשפט."

סעיף זה לא נכלל בחוק הנ"ל ואין להניח שהמחוקק פסח עליו בהיסח הדעת. זאת ועוד: התוצאה שאליה הגעתי, להבדיל מכמה משיקולי, לא היתה משתנה גם אילו היה סעיף זה ממשיך לעמוד בתקפו, שכן על-ידי התניות הכלולות בהסכם הבוררות "נאמר" לפחות מכללא "ההיפך" במובן הסעיף, ובבוא בית-המשפט לדון בבקשתו של צדוק לצוות על הבורר להמשיך בתפקידו, היה עליו לשקול את ההפרה היסודית ולקבוע על יסודה שהביטול היה כדין. אין גם לשכוח שמסירת סכסוך להכרעתו של בורר אינה שוללת, כידוע, את סמכותו של בית-המשפט לדון בנושא, אלא שבהעדר סיבה המצדיקה זאת, יעכב השופט את הדיון כדי שצד להסכם ייאלץ לעמוד בהתחייבותו. לאור ההפרה היסודית מצדו של צדוק שוב אין יסוד, לדעתי, לאלץ את האגודה להיזקק לבוררות.

5. לאור המסקנה שאליה הגעתי, אני רואה צורך לדון בטענתו של בא-כוח האגודה כי הסכם-הבוררות התווה את הדרך היחידה למינויו של הבורר וכי כבר מסיבה זו לא היה בית-המשפט מוסמך למנותו.

כמו-כן איני רואה צורך לדון בשאלה, שכלל לא עלתה על שולחן הדיונים, אם לאור ביטולו של הסכם-הבוררות נפתחה בפני צדוק הדרך לחדש את הדיון בבקשתו לבטל את פסק-דין הפינני.

הייתי מקבלת את הערעור ודוחה את בקשתו של צדוק, תוך חיובו בהוצאות ושכר טרחה למערערת, בשתי הערכאות, בסך 7,500 ל"י.

השופט אשר: אני מסכים שיש לקבל את ערעורה של האגודה, אם כי נימוקי לקבלת הערעור שונים מנימוקי חברתי הנכבדה, השופטת בן-פורת. העובדות החשובות לענייננו הובהרו כבר בחלקן בחוות-דעתה של חברתי, לכן ניתן לסכמן בקיצור:

א. האגודה וצדוק חתמו בתאריך 23.6.1975 על הסכם (להלן - ההסכם) שכלל שטר-בוררין וכמה הוראות נוספות.

ב. שטר-הבוררין חל על סכסוך ישן שקיים היה בין הצדדים, ולא הוחל על סכסוכים נוספים כלשהם בעתיד.

ג. שטר-הבוררין והקשור אליו מהווים את רוב רובו של ההסכם; רק שלושה סעיפים והם סעיפים 3, 15 (א) ו-16 דנים בהתחייבויות שלא נמסרו להכרעת הבורר.

ד. ימים מספר אחרי חתימת ההסכם פנה בא-כוח האגודה אל מר אדמוני וביקשו למנות בורר על-פי שטר-הבוררין, ובתאריך 6.7.1975 מינה מר אדמוני את מר מועלם לשמש כבורר.

ה. הבורר, מר מועלם, הסכים לכהן בתפקיד שיועד לו ובתאריך 9.7.1975 ביקש מהצדדים להגיש את טענותיהם בכתב עד יום 1.8.1975.

ו. בתאריך 28.7.1975 שיגר בא-כוח האגודה מכתב אל צדוק שבו הוא טוען שצדוק לא קיים את התחייבויותיו לפי סעיפים 3, 15 (א) ו-16 ועל-כן יבוטל ההסכם אם לא יבצע צדוק תוך 10 ימים את התחייבויותיו האמורות.

ז. בתאריך 23.9.1975 פנה בא-כוח האגודה אל הבורר והודיע לו על הסכמת האגודה להאריך את הזמן שניתן לצדוק לקיום התחייבויותיו עד למועד קיום ישיבה משותפת לפי הזמנת הבורר.

ח. הבורר קיים ישיבה עם הצדדים בתאריך 8.10.1975; בישיבה זו ביקש מהצדדים שיחתמו על שטר-בוררין חדש אך האגודה סירבה לעשות כן.

ט. בעקבות הישיבה מיום 8.10.1975, הסתלק הבורר מכהונתו, ואישור להסתלקותו נכלל במכתבו מיום 22.1.1976 המופנה אל צדוק. אחרי שניתן פסק-דינו של בית-משפט קמא, אשר הורה על המשכת הבוררות החליט הבורר פעם נוספת להסתלק מכהונתו ועל החלטתו זו הודיע לשני הצדדים במכתב שתאריכו 21.7.1976.

לאור הסתלקותו של הבורר מתפקידו, אין עוד צורך לדון בשאלה אם נהג כדי בישיבה מיום 8.10.1975 כשביקש מהצדדים לחתום על שטר-בוררין חדש. כידוע, אין הצדדים לבוררות יכולים לאכוף על בורר שימשיך לכהן בתפקידו כבורר ואינם יכולים למנוע את התפטרותו. משהתפטר מר מועלם, יכול היה לכאורה כל צד מעוניין לפנות אל בית-המשפט לפי [סעיף 12\(א\) לחוק הבוררות](#), תשכ"ח-1968 (להלן - חוק הבוררות) ולבקש מינויו של בורר חליף. על ענין זה עוד ידובר בהמשך חוות-דעתי, וכאן אסתפק רק בהערה שפניה כזאת אל בית-המשפט אפשרית רק אם שטר-הבוררין שעליו חתמו הצדדים הינו בר-תוקף.

כידוע, טען בא-כוח האגודה שתקפו של שטר-הבוררין פג מאחר והאגודה ביטלה את ההסכם שכלל את שטר-הבוררין. טענה זו אינה מתקבלת על דעתי וזאת משני טעמים:

א. טעמי הראשון הוא שההסכם לא בוטל כדין על-ידי האגודה. [סעיפים 6 ו-7 לחוק החוזים \(תרופות בשל הפרת חוזה\)](#), תשל"א-1970 (להלן - [חוק התרופות](#)), הדנים בביטול חוזה בגלל הפרתו, מבחינים בין הפרה יסודית ושאינה יסודית.

מי שנפגע על-ידי הפרה יסודית רשאי לבטל את החוזה על-ידי מתן הודעת-ביטול תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה.

הנפגע על-ידי הפרה לא-יסודית זכאי לבטל את החוזה אחרי שנתן תחילה ארכה למפר לשם קיומו של החוזה; לא קויים החוזה על-ידי המפר תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, רשאי הנפגע לתת למפר הודעת-ביטול וזאת תוך זמן סביר לאחר שחלפה תקופת הארכה (ראה [סעיף 8](#), סיפא, [לחוק התרופות](#)).

במקרה דנן נתן בא-כוח האגודה ארכה לצדוק, ועצם מתן הארכה הזאת חייב את האגודה לנהוג על-פי הסיפא של [סעיף 8 לחוק התרופות](#) (ראה [ע"א 207/76](#), [2], בע' 93 ובע' 96), כלומר: לתת לצדוק הודעת-ביטול כשתמה תקופת הארכה. במילים אחרות - מכתבו של בא-כוח המערערת מתאריך 28.7.1975, שקבע לכתחילה את מתן הארכה לצדוק, לא הספיק כדי לבטל את ההסכם; דרושה היתה הודעה נוספת - שהיא הודעת-ביטול - אחרי שחלפה תקופת הארכה והודעה כזאת לא הוכחה ואף לא נטענה. מדברי בא-כוח האגודה בסיכומיו נובע שלדעתו היתה הפרתו של צדוק הפרה יסודית ושבגינה ניתן היה לבטל את ההסכם לאלתר. אך הוא לא שם לב לעובדה שהוא עצמו נתן לצדוק ארכה למילוי התחייבויותיו, ואף האריך את תקופת הארכה, ויחד עם זאת סבר כאילו בוטל ההסכם לחלוטין כבר ביום 28.7.1975, ולא היא.

בנסיבות שנוצרו חייב היה בא-כוח האגודה לתת לצדוק הודעת-ביטול אחרי תום תקופת הארכה, בין הודעה פורמלית ובין אחרת, ובהעדר הודעה כזו אין לומר שההסכם בוטל על-ידו. האמור ב-[ע"א 557/75](#), [4], אינו יכול לשנות מהמצב שנוצר מפני שהאגודה לא נתנה כל הודעה, לא פורמלית ואף לא בלתי-פורמלית, על רצונה לבטל את ההסכם.

ב. טעמי השני הוא שאין צד לבוררות רשאי לבטל אותה אחרי שהבוררות נתכוננה והבורר החל לפעול על-פי שטר-הבוררין - אלא בהסכמתו של הצד האחר או באישורו של בית-המשפט. אני ער לכך ששטר-בוררין אינו אלא חוזה ושהוראות [חוק התרופות](#) חלות גם עליו. אך יחד עם זאת סבורני, שאפיו של שטר-בוררין שונה מאפיו של כל

חוזה אחר. התחייבויותיהם של הצדדים על-פי שטר-בוררין אינן התחייבויות מהותיות לעשות דבר מה, או לשלם סכום כסף, או התחייבות מהותית אחר כלשהי. שטר-בוררין אינו מטיל בדרך-כלל התחייבויות של צד זה או אחר, אלא קובע איך ליישב סכסוכים שביניהם. ב-[ע"א 2/49](#), [5], בע' 209, ציטט השופט דונקלבלום המנוח, תוך הסכמה, את דברי הלורד מקמילן (MACMILLAN) שנאמרו בפסק-הדין הידוע [6] HEYMAN V. DARWINS, LTD. (1942):

"הנני חושב כי לא שמו לב במידה מספקת לאפיו האמיתי ולתפקידו של סעיף בחוזה בדבר בוררות, סעיף זה שונה מיתר הסעיפים. יתר הסעיפים מכילים את ההתחייבויות שהצדדים מקבלים על עצמם, אחד כלפי השני; הסעיף בדבר הבוררות איננו מטיל על אחד הצדדים שום התחייבות לטובת הצד השני. הוא מכיל את הסכמת שני הצדדים למסור לבוררות סכסוכים שיתעוררו ביחס להתחייבויות שצד אחד קיבל לטובת הצד השני."

ולמטה מזה הוא הוסיף:

"הסעד המתאים במקרה של הפרת הסכם בדבר בוררות אינו תשלום פיצויים כי אם ביצוע. זאת ועוד: ההבדל האפייני הוא כי לבתי-המשפט באנגליה יש כוח לפטור לפי שיקול דעתם את הצדדים מהוראות סעיף הבוררות, כוח שאין בידי בתי המשפט ביחס ליתר ההוראות שבחוזה."

גם עורך הרבעון THE LAW QUARTERLY REVIEW מדגיש בסקירה המוקדשת לפסק-הדין של, [6 58] HERYMAN V. DARWINS, (L.Q.R. 435) את אפיו המיוחד של שטר-בוררין, וכך הוא אומר:

"If a party refuses to perform his obligations under a contract
It is obvious that he cannot ask that the other party should
Perform his reciprocal obligations, but the obligation to submit
To an arbitration is reciprocal only to the other party's similar
Duty to submit to arbitration, and has nothing to do with the
Other terms of the contract. The doctrine of approbation and
Reprobation is therefore not applicable in these circumstances."

במקרה דנן התקשרו הצדדים בהסכם שבו קיבלו על עצמם התחייבות לכונן בוררות בסכסוך שהיה קיים ביניהם, את ההתחייבות ההדדית הזו הם קיימו במלואה. הם ביקשו למנות את הבורר והוא מונה על-פי בקשתם זו ואף החל לכהן בתפקידו. העובדה שבאותו הסכם קיבל צדוק על עצמו התחייבויות אחרות בנוסף על שטר-הבוררין אינה משנה לענין תקפותו של שטר-הבוררין. יתרה מזו, מן הרגע שהבורר נכנס לתפקידו אין עוד לדבר על אפשרות של הפרת הסכם-הבוררות, כי אותו הסכם כבר בוצע במלואו.

צד

הרוצה, בשלב זה, להסתלק מהבוררות חייב לקבל לכך את הסכמת חברו או רשות מבית- המשפט. מן הרגע שהבוררות נתכוננה היא חיה את חייה העצמאיים והיא כפופה לחוק מיוחד, הוא [חוק הבוררות](#), ולא לחוקי החוזים. משהחל הבורר לכהן על-פי שטר-הבוררין, הוא מוסמך להמשיך בבוררות אפילו ירצה אחד הצדדים לבטל את שטר-הבוררין מסיבה כלשהי. שעה שהחל לדון, היה שטר-הבוררין קיים ותקף, ומשהחלה הבוררות נתמצתה בכך הסכמת הצדדים ואין עוד מה לבטל.

חברתי הנכבדה יצאה מהנחה שלולא התחייבויותיו של צדוק על-פי סעיפים 3, 15(א) ו-16 להסכם, לא היתה האגודה מסכימה למסור את הכרעת הסכסוך שהיה קיים בין הצדדים לבוררות. משום כך היא סבורה שבגלל הפרתו של צדוק ניתן לבטל את ההסכם כולו, לרבו הבוררות שכבר החלה לפעול על-פיו. בדרך-כלל אני מסכים לדעתה שביטולו של הסכם מבטל את כל ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים במידה שמדובר בהתחייבויות שניתן לבטלן ואת כל ההסדרים שכבר בוצעו על-פי ההסכם במידה וניתן להחזיר את המצב לקדמתו; אך לא תמיד הדבר אפשרי. ניקח לדוגמה הסכם-גירושין שבו מתחייבים בני-הזוג להתגרש ויחד עם זאת קובעים, כרגיל, הוראות להסדר עניני הרכוש ביניהם, החזקת הילדים וכו'. משהתגרשו הצדדים בעקבות הסכם כזה, אין עוד לבטל את הגירושין למרות שצד מהצדדים לא עמד בהתחייבויותיו האחרות הכלולות באותו הסכם.

מהאמור לעיל מתבקשת המסקנה שהאגודה לא היתה רשאית לבטל את הבוררות הקיימת, אפילו התיימרה לבטל את ההסכם שכלל את שטר-הבוררין, אך אין במסקנה זו כדי להועיל לצדוק. כאמור, התפטר הבורר מתפקידו באופן סופי ואין אפשרות לכפות עליו שיחזור בו מהתפטרותו. כרגיל במקרה כזה, רשאי כל צד לבוררות לבקש מבית-המשפט שימנה בורר חליף, אלא שעל מינוי כזה חלות הוראות [סעיף 12\(א\) לחוק הבוררות](#), מורות:

12. (א) נתפנתה כהונתו של בורר, אם עקב התפטרותו או פטירתו ואם עקב העברתו מתפקידו, יחולו הוראות הסעיפים 8 עד 10 על מינויו של בורר חליף, והוא כשאינן כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות."

[סעיפים 8 עד 10](#) המוזכרים לעיל קובעים את התנאים והדרך למינויו של בורר חליף, ובמקרה רגיל די בהם כדי להסמיק את בית-המשפט למנות בורר אחר במקרה של התפטרות הבורר המקורי. אלא שהסיפא [לסעיף 12\(א\)](#) היא בעוכריו של צדוק. העיון בהסכם מראה בעליל שכוונת הצדדים היתה למנוע מינויו של בורר חליף על-ידי בית-משפט וזו גם טענתו העיקרית של בא-כוח האגודה בסיכומיו. הוא מפנה אותנו לסעיף 6(ד) של ההסכם שנוסחו הוא:

"6(ד) ההסכמה למסור את השאלות והענינים לבוררות מותנית בתנאי יסודי שהבורר יתמנה אך ורק לפי הוראותיו (של ההסכם - הערה שלי)

ובשום מקרה לא יוכל בורר או בוררים להתמנות על-ידי בית משפט כל שהוא.

נוצרו נסיבות כל שהן, שיש בהן כדי להקנות, מכח הדין, סמכות לבית המשפט למנות בורר יראו, ותנאי זה הוא יסודי, שלא היתה מעולם ואין הסכמה לבוררות בכלל."

אין ספק שכוונת הצדדים המשתמעת מסעיף 6(ד) האמור היא שבית-המשפט לא ימנה בורר חליף בבוררות שהתכוננה על-פי ההסכם. על-כן אי-אפשר לקיים את פסק-דינו של בית-משפט קמא שבו הפנה את צדוק לבית-משפט לשם מינוי בורר אחר במקומו של מר מועלם שהתפטר. מסיבה זו ומסיבה זו בלבד אני מסכים לקבלת ערעורה של האגודה.

השופט שמגר: אני מסכים לתוצאה, ומצטרף לטעמים שהובאו בפסק-דינו של חברי הנכבד, השופט אשר.

הערעור נתקבל. המשיב ישא בהוצאות ושכר טרחה למערערת בשתי הערכאות בסך 7,500 ל"י.

ניתן היום, י"א באלול תשל"ז (25.8.1977).